

Cuatro preguntas que pueden cambiar una ley

El test de proporcionalidad, de la policía prusiana a la Suprema Corte mexicana

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

El test de proporcionalidad es el método con el que un juez decide si una regla que restringe un derecho humano está justificada: pregunta qué fin persigue, si sirve para alcanzarlo, si existe otra medida que dañe menos y si lo que se gana vale lo que se sacrifica. Esta lectura sigue su formación en Alemania, el modelo paralelo de los niveles de escrutinio en los Estados Unidos, la teoría de Robert Alexy y su aplicación en México, grada por grada, en el caso del autoconsumo de marihuana.

PALABRAS CLAVE test de proporcionalidad · ponderación · escrutinio estricto · categorías sospechosas · libre desarrollo de la personalidad · Robert Alexy · amparo en revisión 237/2014

IDEAS CLAVE

- El test hace cuatro preguntas a una regla que restringe un derecho: ¿persigue un fin legítimo?, ¿es idónea?, ¿es necesaria?, ¿es proporcional en sentido estricto?
- Nació en el derecho de policía prusiano: sólo «las medidas necesarias» (1794); la policía no debe disparar con cañones a los gorriones (Fleiner, 1913).
- Los Estados Unidos crearon otro modelo, los niveles de escrutinio: más exigencia cuanto más sospechoso es el criterio de la ley o más importante el derecho.
- México adoptó las dos tradiciones: el escrutinio estricto para las distinciones sospechosas y las cuatro gradas para las libertades.
- El test no derriba la norma general: la ajusta a la medida del derecho y obliga al juez a dar razones.

ÍNDICE

1	Introducción: cuatro preguntas a una ley	2	7	El caso de la marihuana, grada por grada	9
2	El problema: reglas contra principios	2	8	Otros casos, con sus sentencias	10
3	Los orígenes alemanes	3	9	Conclusión	11
4	Estados Unidos: los niveles de escrutinio	5		Glosario	11
5	La teoría y la fórmula: Alexy y Oakes	7		Preguntas para el repaso	12
6	México: dos herramientas	8		Fuentes	12

Introducción: cuatro preguntas a una ley

El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo de cuatro personas y una asociación civil a quienes la autoridad sanitaria había negado un permiso para sembrar, cultivar y consumir marihuana, sólo para sí mismas y sin venderla. La Ley General de Salud prohibía esa autorización sin excepción ¹. La Corte no se preguntó si la marihuana es buena o mala. Le hizo a la ley cuatro preguntas: ¿qué fin persigue?, ¿sirve para alcanzarlo?, ¿existe otro camino que dañe menos?, y ¿vale lo que cuesta? La ley respondió bien las dos primeras y falló las dos últimas.

Esas cuatro preguntas forman el **test de proporcionalidad**: el método con el que un juez decide si una regla que restringe un derecho humano está justificada. Su fuerza está en que no le permite decidir por gusto: lo obliga a mostrar cada razón, paso por paso, a la vista de todos.

El problema: reglas contra principios

Las leyes se escriben con reglas: «está prohibido esto», «es obligatorio aquello», «en ningún caso se permitirá lo otro». Los derechos humanos, en cambio, se formulan como principios: la libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad. Cuando una regla choca con un derecho, el juez enfrenta dos tentaciones igual de peligrosas: aplicar la regla aunque aplaste el derecho, o hacerla a un lado porque no le gusta. El test de proporcionalidad existe para evitar las dos. Sus cuatro gradas son estas:

GRADA	PREGUNTA	RESULTADO EN EL CASO DE LA MARIHUANA
1. Fin constitucionalmente válido	¿La medida persigue un fin legítimo?	Sí: proteger la salud y el orden público
2. Idoneidad	¿Contribuye, en algún grado, a ese fin?	Sí: el consumo causa daños, aunque de escasa entidad
3. Necesidad	¿Existe otra medida igual de eficaz que restrinja menos el derecho?	No pasó: bastaban prohibiciones más específicas
4. Proporcionalidad en sentido estricto	¿Lo que se gana justifica lo que se sacrifica?	No pasó: afectación muy intensa frente a beneficios escasos

Las gradas se recorren en orden, y la medida que no supera una de ellas ya no necesita examinarse en las siguientes. Su historia empieza mucho antes de que existieran los derechos humanos tal como hoy los conocemos.

Los orígenes alemanes

Prusia, 1794: «las medidas necesarias»

El Código General para los Estados Prusianos (*Allgemeines Landrecht*, 1794) definió así la función de la policía:

LEY PRUSIANA *Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794), segunda parte, título 17, § 10* ²

«Tomar las medidas necesarias para conservar la tranquilidad, la seguridad y el orden públicos, y para evitar el peligro que amenace al público o a alguno de sus miembros, es el oficio de la policía.»

TEXTO ORIGINAL (ALEMÁN) «Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit, und Ordnung und zur Abwendung der dem Publico, oder einzelnen Mitgliedern desselben, bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.»

Una palabra de ese artículo iba a tener un largo futuro: *necesarias*. Si la policía sólo puede tomar las medidas necesarias, lo que vaya más allá de lo necesario deja de estar permitido, y los tribunales administrativos prusianos empezaron a revisar las órdenes de policía con esa vara.

Fleiner, 1913: cañones contra gorriones

En 1913, el profesor suizo Fritz Fleiner, que enseñaba derecho administrativo en Heidelberg, lo resumió en una frase que todavía se cita en las facultades de derecho, y la explicó con un ejemplo que contiene, en miniatura, casi todo el test ³:

DOCTRINA

Fritz Fleiner, *Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts*, 3.^a ed., Tubinga, 1913, § 23, pág. 376

«La restricción de la libertad individual nunca debe exceder la medida absolutamente necesaria. La policía no debe disparar con cañones a los gorriones. Si, por ejemplo, un tabernero sirve aguardiente contra lo que permite su licencia, la policía no puede simplemente cerrar la taberna; para alcanzar su fin dispone primero de medios más suaves.»

TEXTO ORIGINAL (ALEMÁN) «Die Beschränkung der individuellen Freiheit darf nie das absolut erforderliche Maß überschreiten. Die Polizei soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Schenkt z. B. ein Wirt zuwider seiner Schankkonzession Branntwein aus, so darf die Polizei nicht einfach die Wirtschaft schließen; ihr stehen zur Erreichung ihres Zweckes zunächst mildere Mittel zur Verfügung.»

Cerrar la taberna sí serviría para detener la falta —sería idóneo—, pero dañaría más de lo necesario.

SEMBLANZA

Fritz Fleiner

1867 – 1937

Derecho administrativo y constitucional.

QUIÉN FUE

Jurista suizo, profesor de derecho público en universidades suizas y alemanas; en 1913 enseñaba en Heidelberg.

QUÉ APORTÓ

Su manual de derecho administrativo sistematizó la jurisprudencia prusiana sobre los límites de la policía. La imagen de los cañones contra los gorriones se volvió la expresión clásica del principio de necesidad.

El Tribunal Constitucional Federal, 1958-1971

La idea se volvió constitucional después de la catástrofe del nazismo. La Ley Fundamental alemana de 1949 abrió con una frase: «la dignidad humana es intangible»⁴. El nuevo Tribunal Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe, tuvo que decidir qué hacer cuando un derecho choca con otros bienes.

Lüth (1958). En 1950, Erich Lüth, un funcionario de Hamburgo, llamó a boicotear la nueva película de Veit Harlan, el director de *El judío Süß*, la película antisemita de la propaganda nazi. Un tribunal de Hamburgo le prohibió seguir haciéndolo. El 15 de enero de 1958, el Tribunal Constitucional le dio la razón: los derechos fundamentales, escribió, encarnan también «un orden objetivo de valores», y cuando la libertad de expresión choca con otros intereses es necesaria una «ponderación de bienes»⁵.

La farmacia de Traunreut (1958). Ese mismo año, el gobierno de Baviera negó a un farmacéutico el permiso para abrir una farmacia en Traunreut, porque la que ya existía perdería ventas. El Tribunal le dio la razón y construyó una escala para la libertad de profesión: cuanto más hondo corta la ley en esa libertad, más pesadas tienen que ser sus razones; y si el legislador tiene que intervenir, «debe escoger siempre la forma de intervención que menos limite el derecho fundamental»⁶.

El almacenamiento de petróleo (1971). En 1971, el mismo tribunal definió con precisión las gradas centrales del test:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN

BVerfGE 30, 292 (*Erdölbevorratung*), resolución de 16 de marzo de 1971

«El medio empleado por el legislador debe ser idóneo y necesario para alcanzar el fin perseguido. El medio es idóneo si con su ayuda puede favorecerse el resultado deseado; es necesario si el legislador no hubiera podido elegir otro medio igualmente eficaz que no restringiera el derecho fundamental, o que lo restringiera de manera menos sensible.»

«En una ponderación global entre la gravedad de la intervención y el peso y la urgencia de las razones que la justifican, debe respetarse todavía el límite de lo exigible.»

Traducción propia⁷

PRECISIÓN Los niveles (*Stufen*) de la sentencia de las farmacias son grados de intervención en la libertad de profesión, no las cuatro gradas del test. La formulación de las gradas como hoy se conocen se consolidó en la jurisprudencia posterior, como la de 1971.

Estados Unidos: los niveles de escrutinio

Lochner y la lección de 1905

Del otro lado del Atlántico, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprendió una lección distinta. En 1905, en *Lochner v. New York*, anuló una ley que prohibía que los panaderos trabajaran más de diez horas al día y sesenta a la semana, por considerarla «una intromisión irrazonable, innecesaria y arbitraria» en la libertad de contratar. El juez Oliver Wendell Holmes escribió en su voto disidente que el caso se decidía «con una teoría económica que gran parte del país no comparte»⁸. Durante tres décadas, aquella Corte anuló numerosas leyes laborales y sociales. La lección fue amarga: un juez que pondera sin método termina imponiendo sus propias ideas.

SEMBLANZA

Oliver Wendell Holmes Jr.

1841 – 1935

Derecho; filosofía del derecho.

QUIÉN FUE

Jurista estadounidense, autor de *The Common Law* (1881) y ministro de la Corte Suprema de 1902 a 1932.

QUÉ APORTÓ

Sus votos disidentes defendieron la deferencia al legislador democrático en materia económica y la libertad de expresión. Su disidencia en *Lochner* es una de las más citadas de la historia judicial.

Carolene Products y la nota 4 (1938)

En 1938, la Corte cambió de rumbo. En *United States v. Carolene Products*, el juez Harlan Fiske Stone escribió que las leyes económicas debían presumirse constitucionales, pero en la nota cuatro, al pie de la página, dejó abierta una puerta⁹:

CORTE SUPREMA DE EE. UU.

United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938), nota 4

«[...] si el prejuicio contra minorías aisladas y separadas puede ser una condición especial que tiende a reducir seriamente el funcionamiento de los procesos políticos en los que ordinariamente se confía para proteger a las minorías, y que puede exigir un examen judicial correspondientemente más riguroso.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) «[...] whether prejudice against discrete and insular minorities may be a special condition, which tends seriously to curtail the operation of those political processes ordinarily to be relied upon to protect minorities, and which may call for a correspondingly more searching judicial inquiry.»

De esa nota nacieron los niveles de escrutinio: una revisión benévola para casi todas las leyes y una estricta para las que tocan derechos fundamentales o usan criterios sospechosos, como la raza.

SEMBLANZA

Harlan Fiske Stone

1872 – 1946

Derecho constitucional.

QUIÉN FUE

Decano de la Facultad de Derecho de Columbia, procurador general de los Estados Unidos y ministro de la Corte Suprema desde 1925; la presidió de 1941 a 1946.

QUÉ APORTÓ

La nota 4 de *Carolene Products* fundó la idea de que los jueces deben ser más exigentes cuando una ley afecta a minorías que el proceso político no protege.

Korematsu y Loving: el escrutinio estricto

La fórmula del escrutinio más riguroso quedó escrita, paradójicamente, en una de las sentencias más vergonzosas de esa Corte. En diciembre de 1944, en el caso de Fred Korematsu, un ciudadano estadounidense de ascendencia japonesa, el juez Hugo Black escribió que toda restricción de los derechos civiles de un solo grupo racial es «inmediatamente sospechosa» y debe someterse «al escrutinio más riguroso». Y aun así, la Corte validó la orden militar que expulsó de la costa oeste a las personas de ascendencia japonesa, que terminaron en campos de internamiento¹⁰. El escrutinio estaba anunciado; nadie lo aplicó.

Hizo falta otra generación para que mostrara su fuerza. En 1958, Mildred Jeter, una mujer negra, y Richard Loving, un hombre blanco, se casaron en Washington; al volver a Virginia, donde ese matrimonio era delito, fueron condenados a un año de prisión, suspendido a condición de que salieran del estado y no volvieran juntos en veinticinco años. En 1967, la Corte resolvió por unanimidad que una distinción racial sólo puede sostenerse si es «necesaria para lograr algún objetivo estatal permitido», y que aquélla no tenía más propósito que discriminar¹¹. Cinco años después, el profesor Gerald Gunther resumió el resultado en una frase célebre: el escrutinio estricto es «estricto en la teoría, fatal en los hechos»¹².

Ruth Bader Ginsburg, Thurgood Marshall y el escrutinio intermedio

En 1971, una abogada firmó el escrito del caso *Reed v. Reed*: Ruth Bader Ginsburg. Una ley de Idaho ordenaba que, entre dos personas con el mismo derecho a administrar una herencia, «los hombres deben ser preferidos a las mujeres». La Corte anuló esa preferencia por unanimidad: fue la primera vez que invalidó una ley por discriminar por razón de sexo¹³.

La Corte trabajaba entonces con dos cajas: escrutinio estricto o simple racionalidad. En 1973, en un caso promovido por padres mexicoamericanos de San Antonio, Texas, cuyos hijos estudiaban en escuelas con menos recursos por vivir en un distrito pobre, la mayoría les negó la razón por cinco votos contra cuatro. Thurgood Marshall escribió en su voto disidente que la Corte, en realidad, aplicaba «un espectro de estándares»: el cuidado con que revisa una ley depende de la importancia constitucional del interés afectado y de lo odioso del criterio con que distingue¹⁴. Era, con otras palabras, una balanza.

Ese mismo año, Ginsburg defendió ante la Corte a Sharron Frontiero, una oficial de la Fuerza Aérea a quien se exigía probar que su esposo dependía de ella para recibir los beneficios que las esposas de los militares obtenían sin probar nada. Cuatro jueces, Marshall entre ellos, quisieron tratar el sexo como categoría sospechosa; faltó un voto¹⁵. En 1976, en *Craig v. Boren* —una ley de Oklahoma permitía comprar cerveza de baja graduación a las

mujeres desde los dieciocho años y a los hombres desde los veintiuno—, la Corte creó un tercer nivel: una distinción por sexo debe servir a «objetivos gubernamentales importantes» y estar «sustancialmente relacionada» con ellos ¹⁶. Y en 1996, ya como jueza de la Corte Suprema, Ginsburg escribió la sentencia del Instituto Militar de Virginia: quien distinga por sexo debe ofrecer una «justificación sumamente persuasiva», auténtica y no inventada después para defenderse en el juicio ¹⁷.

NIVEL	CUÁNDO SE APLICA	QUÉ EXIGE A LA LEY
Racionalidad	Casi todas las leyes, en especial las económicas	Un fin legítimo y una relación razonable con él
Intermedio	Distinciones por sexo (<i>Craig</i> , 1976)	Objetivos importantes y una relación sustancial con ellos
Estricto	Distinciones por raza y derechos fundamentales (<i>Loving</i> , 1967)	Un interés imperioso y una medida necesaria para lograrlo

SEMBLANZA

Ruth Bader Ginsburg

1933 – 2020

Derecho constitucional; igualdad de género.

QUIÉN FUE

Abogada y profesora estadounidense. Litigó ante la Corte Suprema los grandes casos de discriminación por sexo de los años setenta y fue ministra de esa Corte de 1993 a 2020.

QUÉ APORTÓ

Construyó, caso por caso, el escrutinio de las distinciones por sexo. Como ministra escribió *United States v. Virginia* (1996), que exige una justificación «sumamente persuasiva».

SEMBLANZA

Thurgood Marshall

1908 – 1993

Derecho constitucional; derechos civiles.

QUIÉN FUE

Abogado de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, ganó *Brown v. Board of Education* (1954) contra la segregación escolar. Fue el primer ministro afroamericano de la Corte Suprema (1967-1991).

QUÉ APORTÓ

Su idea de un «espectro de estándares» anticipó una revisión graduada según la importancia del derecho, cercana a la ponderación.

La teoría y la fórmula: Alexy y Oakes

Robert Alexy y la ley de la ponderación

Mientras en los Estados Unidos se discutía en qué caja poner cada ley, en Alemania el jurista Robert Alexy dio al método su teoría. En 1985 publicó la *Teoría de los derechos fundamentales*, traducida al español en 1993. Su idea central es que las reglas se cumplen o no se cumplen, mientras que los derechos son principios: «normas que ordenan que algo sea

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes», es decir, mandatos de optimización ¹⁸. Por eso, cuando dos principios chocan, ninguno se anula: se pesan.

DOCTRINA

Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, prefacio a la 3.ª edición en castellano (CEPC) ¹⁸

«La ley de ponderación reza: Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro.»

«Estoy de acuerdo con la tesis de que la fundamentación no puede ser reemplazada por números.»

SEMBLANZA**Robert Alexy**

Nació en 1945

Filosofía del derecho; derecho constitucional.

QUIÉN FUE

Jurista alemán, profesor de la Universidad de Kiel. Autor de la *Teoría de la argumentación jurídica* (1978) y de la *Teoría de los derechos fundamentales* (1985).

QUÉ APORTÓ

Explicó los derechos fundamentales como principios que se ponderan y formuló la ley de la ponderación, hoy presente en la jurisprudencia constitucional de muchos países, incluido México.

Canadá, 1986: el caso Oakes

Al año siguiente, la escalera llegó al derecho anglosajón. David Oakes fue detenido con ocho frascos de aceite de hachís, y una ley lo obligaba a probar que no los tenía para traficar. En febrero de 1986, la Corte Suprema de Canadá, presidida por Brian Dickson, fijó las condiciones para limitar un derecho de la Carta canadiense: un objetivo suficientemente importante; medidas «racionalmente conectadas» con ese objetivo; que afecten el derecho «lo menos posible»; y proporción entre los efectos de la medida y el objetivo ¹⁹. La presunción no superó el examen: poseer una cantidad pequeña de droga no permite suponer que alguien trafica.

México: dos herramientas***Escrutinio e igualdad (2004-2007)***

México tomó las dos tradiciones. En 2004, la Primera Sala adoptó la idea estadounidense: cuando una ley distingue por motivos como el origen étnico, el género o la religión, el juez constitucional debe someter la labor del legislador «a un escrutinio especialmente cuidadoso» ²⁰. En 2006 fijó los pasos para examinar cualquier distinción legal —una finalidad constitucionalmente válida, un medio apto para alcanzarla y proporcionalidad—, porque «la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos» ²¹.

El caso que llevó el test al Pleno tenía rostro. La ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas declaraba inútiles para el servicio a los militares que vivían con VIH y, por esa causa, los retiraba del activo. En 2007, el Pleno aceptó que la finalidad era legítima, pero concluyó que la medida era inadecuada y desproporcionada:

TESIS DEL SEMANARIOJurisprudencia P./J. 131/2007, Pleno de la Suprema Corte, diciembre de 2007 ²²

«El legislador a través de dicha causa legal de retiro persigue, como finalidad constitucionalmente válida, la eficacia de las fuerzas armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y de terceros; sin embargo, dicha regulación [...] carece de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, toda vez que: 1) es inadecuada para alcanzar la finalidad mencionada, porque la ciencia médica [...] ha demostrado la inexactitud de que quienes porten dichos virus sean -per se- agentes de contagio directo [...]; 2) es desproporcional, porque el legislador, para alcanzar el mencionado objetivo, tenía a su disposición alternativas menos gravosas para el militar implicado, considerando que la legislación castrense hace posible su traslado a un área distinta [...].»

De esos amparos salió también una jurisprudencia obligatoria: la ley que restrinja un derecho debe «a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria», y estar justificada en razones constitucionales ²³.

La reforma de 2011 y el escrutinio estricto

El 10 de junio de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ordenó interpretar las normas «favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia» y obligó a todas las autoridades a «promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos» (art. 1.º) ²⁴. Con ese mandato, la Corte afinó sus dos herramientas. Para las distinciones sospechosas adoptó, casi palabra por palabra, el escrutinio estricto estadounidense: la medida debe cumplir «una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional», estar «estrechamente vinculada» con ella y ser «la medida menos restrictiva» posible ²⁵. Para las libertades, la escalera alemana de cuatro gradas.

El caso de la marihuana, grada por grada

Los hechos

Cuatro personas y la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante pidieron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios una autorización para el consumo personal con fines lúdicos: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana, sin comerciar con ella. En junio de 2013, la Comisión se la negó, porque la Ley General de Salud sólo permitía esas actividades con fines médicos y científicos. El amparo llegó a la Primera Sala, que recorrió las cuatro gradas ¹.

Las cuatro gradas

Fin y idoneidad. La prohibición perseguía fines constitucionalmente válidos: proteger la salud y el orden público. La Corte revisó la evidencia científica y concluyó que el consumo de marihuana causa daños a la salud, aunque, en términos generales, se trata de «daños de escasa entidad», y que prohibirlo «efectivamente es una medida idónea» para evitarlos ¹. La ley superó las dos primeras gradas.

Necesidad. Aquí la pregunta cambia: ya no basta con que la medida sirva; hay que averiguar si existe otra igual de eficaz que afecte menos el derecho. Y existía. El legislador podía prohibir conductas concretas, «como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o inducir a terceros a que también la consuman». En lugar de eso, prohibió el consumo en cualquier circunstancia: un sistema, dijo la Corte, «altamente suprainclusivo», que abarca muchos más casos de los que su propia justificación alcanza ¹. Era, otra vez, un cañón contra un gorrión.

Proporcionalidad en sentido estricto. En un platillo de la balanza estaba la afectación al libre desarrollo de la personalidad, que la Corte calificó de «muy intensa», porque la prohibición «suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho»; en el otro, una protección de la salud y del orden público que la propia evidencia mostraba escasa. La balanza se inclinó del lado de la libertad, y la Corte amparó a los quejosos ¹.

Lo que la Corte no hizo

La sentencia no legalizó la marihuana ni borró la ley. Precisó que la autorización «no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio» y que «el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros» ¹. Lo que quitó fue el exceso: la parte de la regla que iba más allá de lo necesario. Es la taberna de Fleiner: sancionar la conducta que daña, sin cerrar la vida entera de los demás.

De la sentencia a la regla general

Un amparo protege sólo a quien lo pidió. En 2018, la Primera Sala repitió el análisis en otros cuatro amparos y, en febrero de 2019, con cinco sentencias en el mismo sentido, el criterio se volvió jurisprudencia ²⁶. El Congreso no corrigió la ley en el plazo que se le dio, y el 28 de junio de 2021 el Pleno, por ocho votos, emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad: expulsó de la Ley General de Salud la porción «sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y», con efectos para todos, y precisó que el autoconsumo nunca puede ejercerse frente a menores, ni ante terceros que no lo consientan, ni al conducir ²⁷.

Otros casos, con sus sentencias

El test se ha aplicado en muchos otros asuntos. Su resultado no está decidido de antemano: a veces la ley lo supera.

AÑO	CASO	RESULTADO
2015	Matrimonio definido por la procreación	«Medida no idónea» para proteger a la familia ²⁸
2015	Divorcio sólo por causales	No idónea: basta con que uno de los cónyuges lo pida ²⁹
2017	Trescientos días de espera para que una mujer vuelva a casarse (Puebla)	Desproporcionada: existen pruebas genéticas de paternidad ³⁰
2017	Impuesto a los alimentos de alta densidad calórica	«Supera el test de proporcionalidad» ³¹
2020	Prohibición absoluta de la reventa de boletos (Ciudad de México)	No supera la grada de necesidad ³²

Conclusión

En ninguno de estos casos el juez dijo que la ley no le gustaba. En todos tuvo que mostrar qué buscaba la regla, si servía, si había otra forma menos dañina y si el sacrificio valía la pena. Cuando la respuesta fue afirmativa, la regla se quedó: el test no es un arma contra el legislador, sino una obligación de dar razones. La propia Segunda Sala lo ha llamado «tan sólo una herramienta interpretativa y argumentativa más» ³³, y Alexy advierte que la fundamentación no puede reemplazarse por números: el método sólo ordena la argumentación ¹⁸.

De la policía de Prusia a la Ley General de Salud, la pregunta ha sido la misma durante más de dos siglos: si el Estado puede lograr su fin dañando menos, está obligado a hacerlo. Pero ninguna fórmula funciona sola. El test necesita jueces independientes, dispuestos a hacerle las cuatro preguntas también al poder.

Glosario

Test de proporcionalidad

Método para decidir si una medida que restringe un derecho está justificada, mediante cuatro gradas: fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Idoneidad

Aptitud de la medida para contribuir, en algún grado, al fin que persigue.

Necesidad

Exigencia de que no exista otra medida igualmente eficaz que restrinja menos el derecho.

Proporcionalidad en sentido estricto

Comparación entre el beneficio que la medida produce y la afectación que causa al derecho.

Ponderación

Operación de pesar dos principios en conflicto según su importancia en el caso concreto.

Escrutinio estricto

Examen judicial reforzado de las distinciones basadas en categorías sospechosas, que exige una finalidad imperiosa y la medida menos restrictiva.

Categoría sospechosa

Criterio de distinción, como la raza, el sexo o la religión, que hace presumir que una ley discrimina.

Declaratoria general de inconstitucionalidad

Resolución de la Suprema Corte que expulsa una norma con efectos para todos, tras una jurisprudencia que el legislador no corrigió.

Preguntas para el repaso

1. ¿Cuáles son las cuatro gradas del test de proporcionalidad y en qué orden se examinan?
2. ¿Qué relación hay entre la frase de Fleiner sobre los cañones y los gorriones y la grada de necesidad?
3. ¿Qué lección dejó el caso *Lochner* sobre los riesgos de ponderar sin método?
4. Compare los niveles de escrutinio estadounidenses con la escalera alemana. ¿Qué tomó México de cada tradición?
5. ¿Por qué la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana superó la idoneidad pero no la necesidad?
6. ¿Por qué se dice que el test no derriba la norma general, sino que la ajusta?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Cuatro preguntas que pueden cambiar una ley. El test de proporcionalidad, de la policía prusiana a la Suprema Corte mexicana», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo en revisión 237/2014, sentencia de 4 de noviembre de 2015, versión pública (síntesis, pág. III; sentencia, págs. 65, 75-76, 79-80 y 90). <https://www.scjn.gob.mx/de-rechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2020-01/AR%20237-2014%20v.%20p%C3%BAblica%20PDF.pdf>
2. DOCUMENTO HISTÓRICO *Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten* (1794), segunda parte, título 17, § 10 (Bayerische Staatsbibliothek). <https://archive.org/details/10726093bsb/page/n311/mode/1up>
3. DOCTRINA Fritz Fleiner, *Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts*, 3.^a ed., Tubinga, 1913, § 23, pág. 376. <https://archive.org/details/institutionendes00flei>
4. CONSTITUCIÓN Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949), art. 1, párr. 1. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html
5. TRIBUNAL EXTRANJERO Tribunal Constitucional Federal alemán, BVerfGE 7, 198 (*Lüth*), sentencia de 15 de enero de 1958. <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv007198.html>

6. TRIBUNAL EXTRANJERO Tribunal Constitucional Federal alemán, BVerfGE 7, 377 (*Apotheken-Urteil*), sentencia de 11 de junio de 1958. <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv007377.html>
7. TRIBUNAL EXTRANJERO Tribunal Constitucional Federal alemán, BVerfGE 30, 292 (*Erdölbevorratung*), resolución de 16 de marzo de 1971. <https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv030292.html>
8. ESTADOS UNIDOS *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45 (1905), y voto disidente de Oliver Wendell Holmes. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep198/usrep198045/usrep198045.pdf>
9. ESTADOS UNIDOS *United States v. Carolene Products Co.*, 304 U.S. 144 (1938), nota 4. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep304/usrep304144/usrep304144.pdf>
10. ESTADOS UNIDOS *Korematsu v. United States*, 323 U.S. 214 (1944). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep323/usrep323214/usrep323214.pdf>
11. ESTADOS UNIDOS *Loving v. Virginia*, 388 U.S. 1 (1967). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep388/usrep388001/usrep388001.pdf>
12. DOCTRINA Gerald Gunther, «Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court», *Harvard Law Review*, vol. 86, 1972, pp. 1 y 8.
13. ESTADOS UNIDOS *Reed v. Reed*, 404 U.S. 71 (1971). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep404/usrep404071/usrep404071.pdf>
14. ESTADOS UNIDOS *San Antonio Independent School District v. Rodriguez*, 411 U.S. 1 (1973), voto disidente de Thurgood Marshall, págs. 98-99. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep411/usrep411001/usrep411001.pdf>
15. ESTADOS UNIDOS *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677 (1973). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep411/usrep411677/usrep411677.pdf>
16. ESTADOS UNIDOS *Craig v. Boren*, 429 U.S. 190 (1976). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep429/usrep429190/usrep429190.pdf>
17. ESTADOS UNIDOS *United States v. Virginia*, 518 U.S. 515 (1996), opinión de Ruth Bader Ginsburg. <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep518/usrep518515/usrep518515.pdf>
18. DOCTRINA Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, Madrid, CEC, 1993, pág. 86; prefacio a la 3.ª ed. en castellano, CEPC, 2022. <https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-08/a-1012-primera-s-p-2229-teoria-de-los-derechos-fundamentales-3ed-ferros-2.pdf>
19. TRIBUNAL EXTRANJERO Corte Suprema de Canadá, *R. v. Oakes*, [1986] 1 S.C.R. 103, 28 de febrero de 1986, pág. 139. <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/117/index.do>
20. TESIS DEL SEMANARIO Tesis 1a. CXXXIII/2004, Primera Sala (amparo directo en revisión 988/2004), registro digital 179904. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/179904>
21. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 55/2006, Primera Sala, registro digital 174247. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174247>
22. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 131/2007, Pleno (amparo en revisión 2146/2005 y otros), registro digital 170590. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170590>
23. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia P./J. 130/2007, Pleno, registro digital 170740. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170740>
24. DIARIO OFICIAL *Diario Oficial de la Federación*, 10 de junio de 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos, art. 1.º https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf
25. TESIS DEL SEMANARIO Tesis 1a. CI/2013 (10a.), Primera Sala, registro digital 2003250; véase también la jurisprudencia 1a./J. 87/2015 (registro 2010595). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003250>
26. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 10/2019 (10a.), Primera Sala, febrero de 2019, registro digital 2019365. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019365>
27. SUPREMA CORTE SCJN, Pleno, declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, resolución de 28 de junio de 2021. <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2022-07/DGI%201-2018.pdf>
28. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 43/2015 (10a.), Primera Sala, registro digital 2009407. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009407>
29. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), Primera Sala, registro digital 2009591. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009591>
30. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis VI.3o.C.4 C (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, 2017, registro digital 2014901. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014901>
31. TESIS DEL SEMANARIO Tesis 2a. XCI/2017 (10a.), Segunda Sala, junio de 2017, registro digital 2014439. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014439>
32. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis I.6o.A.28 A (10a.), Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 2020, registro digital 2021906. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021906>
33. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 2a./J. 10/2019 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2019276. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019276>